

0001885-98.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra o Patrimônio

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... NÃO BUSCADA NA ORIGEM. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS IN CASU: CAMPANA PRÉVIA E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO PELO COMPARSA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MODUS OPERANDI. PACIENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001885-98.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001885-98.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Patrimônio

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028993/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 15985950 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 21/21/566 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2028993 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI BARBOSA TORCIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado GIOVANI BARBOSA TORCIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por três vezes, no art. 155, § 4º, incisos III e IV do Código Penal. Consta da denúncia que o acusado, no dia 07 de janeiro de 2021, às 16h30min, na Rua Vitório Mancuso, quadra 01, bairro Distrito Industrial, nesta cidade de Bauru-SP, subtraiu, para si, o veículo Ford/Esport, placas FBA-3385, preta, mediante o concurso de duas pessoas e com emprego de chave falsa. Consta ainda da inicial, que o acusado, no dia 14 de janeiro de 2021, na Rua Prudente de Moraes, bairro Vila Souto, nesta cidade de Bauru/SP, subtraiu, para si, a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa FBG-6936, preta, mediante o concurso de duas pessoas e com emprego de chave falsa.

Consta, por fim, da inicial, que o acusado, no dia 28 de janeiro de 2021, na Rua Doze de Outubro, em frente ao número 10-70, bairro Vila São João da Boa Vista, nesta cidade de Bauru/SP, subtraiu, para si, uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa EHY-1263, roxa, da vítima Thiago Henrique Vilela, mediante o concurso de duas pessoas e com emprego de chave falsa.

Boletim de ocorrência (fls. 09/12), autos de exibição/apreensão (fls. 15 e 19/20), laudo pericial do veículo (fls. 195/200), laudo de objetos (fls. 201/207), relatório final (fls. 33/39).

Pela decisão de fls. 49/61, foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Nos autos do Habeas Corpus nº 2035303-12.2021.8.26.0000 foi indeferida a liminar, outrora pleiteada pelo réu (fls. 87/102).

Pela decisão de fls. 173/175 foi determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 219), sendo ofertada a respectiva resposta à acusação (fls. 214/217).

Na decisão de fls. 224/225, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 316/320 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu. No mesmo ato solene foi concedida a liberdade provisória ao acusado, com a imposição de cautelares.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 333/344 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como, pela exasperação da pena-base, como circunstância judicial desfavorável, no tocante a uma das duas qualificadoras previstas; a valoração da agravante do "estado pandêmico", com a fixação do regime semiaberto.

Já a Defesa às fls. 358/427, em síntese, pleiteou, em preliminares, pela nulidade da produção de provas, em razão da oitiva das testemunhas com mácula ao sistema do cross examination (art. 212 do CPP); a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, forte na teoria dos frutos da árvore envenenada; da invalidade do recebimento da denúncia pela ausência de oferecimento do ANPP, pela presença dos requisitos legais; e, no mérito, ausência de provas da autoria, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a infração penal de receptação culposa, a constatação do crime continuado; a restituição da motocicleta apreendida às fls. 20.

Na decisão de fls. 428, foi determinada a manifestação do Ministério Público, precipuamente, acerca das preliminares alegadas.

No parecer de fls. 434/442 o parquet opinou pela rejeição das preliminares.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

As preliminares devem ser rejeitadas.

De início, importante citar que a motocicleta foi apreendida na casa de Tiago.

E, mesmo ele sendo interrogado, jamais mencionou que os policiais não teriam observado a autorização para adentrar no imóvel (fls. 17).

O próprio acusado ouvido às fls. 18, jamais citou tal circunstância.

Ademais, os policiais foram claros em mencionar que havia investigações pretéritas, e que, quanto à apreensão foi realizada campana.

É dizer, havia fundadas razões.

Com todo respeito a posicionamento em contrário, e isso é suficiente, eis que havia fundada suspeita ante o conjunto probatório delineado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO BUSCADA NA ORIGEM. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS IN CASU: CAMPANA PRÉVIA E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO PELO COMPARSA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MODUS OPERANDI. PACIENTE REINCIDENTE E CONSIDERADO MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NOS AUTOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia de que o paciente, considerado membro de conhecida organização criminosa, praticava a traficância. Em campanha prévia, os policiais visualizaram a motocicleta indicada como sendo do paciente e o carro roubado que era utilizado pelo comparsa. Não obstante a tentativa de fuga dos corréus, com a quebra de aparelho celular pelo comparsa, os policiais avistaram drogas na residência e sentiram forte cheiro de entorpecentes que dela advinha. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somada aos petrechos e ao dinheiro encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 693758 / MT, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 07/12/2021)

Depois, importante citar que as declarações dos policiais, no aspecto, são dignas de fé, tendo em vista que a documentação e registro audiovisual das diligências policiais não mais são necessárias, nos termos do RE 1342077/SP, de relatoria do Douto Ministro Dr. Alexandre de Moraes.

De outro lado, não há invalidade pelo não oferecimento do ANPP pelo MP, eis que uma vez suscitada a tese, o órgão acusatório foi instado a se manifestar.

O acusado foi denunciado por três crimes de furto, todos com duas qualificadoras. Portanto, incabível abstratamente o acordo, tendo em vista a habitualidade das condutas, nos termos do art. 28-A, §2º, II do CPP.

Além disso, referido acordo não se trata de “direito subjetivo” do acusado, além de ser atribuição única do Ministério Público, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido o item 2 da edição nº 185 da Ferramenta “Jurisprudência em Teses” do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 2) O acordo de não persecução penal - ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, assim pode ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais.

Sob outro vértice, eventual mácula ao sistema “cross examination” não pode representar invalidade de cunho absoluto.

Em outras palavras, necessária a comprovação do prejuízo, o qual não se presume.

Adicione-se que também não foi comprovado prejuízo no caso em testilha. É máxima da Teoria das Nulidades no Processo Penal que não há que se falar em nulidade sem comprovação de prejuízo.

Além do que, é o que preconiza a r. jurisprudência, em posição ainda majoritária [info-1012-stf.pdf](https://www.stf.jus.br/portal/publicacao/pesquisa?termo=1012-stf.pdf) (wordpress.com) www.dizerodireito.com.br.

Nesse sentido:

A inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. A defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).

(STF. 1ª Turma. HC 177530 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/12/2019).

Na mesma toada, o item 12 da Ferramenta “Jurisprudência em Teses”, do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 12: A inquirição das testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa.

Importante mencionar que a defesa nas alegações finais, mais precisamente às fls. 370/375, nada elucidou no aspecto (isto é, acerca do eventual prejuízo).

Por fim, não se pode olvidar que a prova é direcionada ao processo (diga-se ao magistrado), visando, sempre, a busca da verdade substancial.

Por tudo, sempre com respeito ao pensamento em contrário, REJEITO as preliminares. Ao mérito.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), autos de exibição/apreensão (fls. 15 e 19/20), laudo pericial do veículo (fls. 195/200), laudo de objetos (fls. 201/207), relatório final (fls. 33/39).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, apenas no tocante a parte dos crimes, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Thiago Henrique Vilela, ouvida somente durante o inquisitivo (fls. 13), disse que foi avisado por investigadores de polícia acerca da recuperação de sua motocicleta, uma Honda CG/125, placa EHY-1263, que havia sido subtraída no dia 28 de janeiro de 2021. Afirmou que, na ocasião, deixou a motocicleta estacionada na Rua 12 de Outubro, mas, quando retornou, o veículo havia sido levado.

A ofendida Andreia Borges, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse que, no dia 07 de janeiro deste ano, seu marido deixou seu carro, um Ford/Ecosport, na via pública e entrou na empresa para trabalhar, mas, momento após, retornou para buscar um documento e notou que o veículo tinha sido subtraído. Afirmou que recebeu uma multa quando o réu conduziu seu automóvel durante o furto, às 16h45. Informou que o veículo foi arrombado, já que ele estava trancado e sem as chaves. Esclareceu que seu automóvel não foi encontrado, tendo prejuízo de cerca de 34 mil reais, pois não era segurado.

A ofendida Kemelly Cunha de Mello, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse que deixou sua motocicleta estacionada na Rua Venceslau Brás, mas quando retornou, por volta das 17h, notou que ela havia sido subtraída. Afirmou que conseguiu imagens de câmeras de empresas vizinhas, sendo possível perceber que o crime foi praticado por duas pessoas que se utilizaram de uma moto vermelha durante a ação ilícita. Informou que um dos agentes usava uma camiseta preta do Brasil e tinha capacete vermelho, enquanto o outro tinha capacete preto. Esclareceu que não conseguiu recuperar sua motocicleta, tendo prejuízo financeiro, porque não possuía seguro.

A testemunha Tiago Fernando Rodigheiro sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse que estava na posse da motocicleta Honda/CG, que era "NP". Afirmou que ele e o acusado receberam a moto para desmanchá-la. Negou que tivesse dito aos policiais que foi o réu quem furtou a motocicleta. Confirmou que o acusado tinha uma motocicleta "Start", cor vermelha, mas não soube dizer se a família dele tinha algum SUV prata. Citou que não autorizou os policiais a entrarem em seu imóvel.

A policial civil Renata Karine Gonçalves, na fase judicial (mídia SAJ) disse que a polícia iniciou uma investigação acerca do furto do veículo Ford/Ecosport, e obteve imagens de câmeras de vigilância que flagraram a prática delitiva. Afirmou que investigações, de forma pretérita, um indivíduo de nome Giovani, que estaria cometendo furtos em Bauru com o uso de uma moto vermelha ou um SUV prata. Informou que receberam informação no sentido de que outra pessoa, chamada Tiago Rodigueiro, estaria na posse da motocicleta furtada no dia 28 de janeiro. Esclareceu que, em campana, pela residência de Tiago, o flagraram, assim como o acusado, chegando ao local, cada qual com uma motocicleta. Mencionou que encontraram, no imóvel, a motocicleta Honda CG-125, placas EHY- 1263, de cor roxa, já pronta para ser desmanchada. Citou que, na posse do réu, havia ferramentas para desmontar veículos. Asseverou que o Hyundai/Tucson de cor prata usado na prática dos crimes pertencia à genitora do réu.

O policial civil Hugo Bolzan Silveira, em Juízo (mídia SAJ), disse, em síntese, que a polícia tinha a informação de que uma pessoa chamada Giovani, na companhia de outras pessoas, estaria praticando furtos pela cidade. Afirmou que obtiveram imagens desse local, onde foi possível visualizar, no dia do crime, uma Ecosport preta e um SUV prata chegando juntos. Informou que descobriram que um SUV prata fornecia apoio ao crime. Esclareceu que, em janeiro deste ano, houve o furto de uma motocicleta CG e, na posse das imagens do local, flagraram duas pessoas subtraindo o veículo, sendo que um deles estava numa moto vermelha. Mencionou que houve um novo furto de outra moto, cujas características físicas eram as mesmas dos demais crimes. Citou receberam novas informações de que Tiago Rodigheiro estaria na posse de uma das motos subtraídas. Asseverou que fizeram campana na frente da casa de Tiago, quando o avistaram com o acusado, sendo que ambos foram abordados. Disse que, no imóvel de Tiago, foi localizada a Honda CG-125, placas EHY-1263, de cor roxa, que fora subtraída na sexta-feira anterior e que já estava pronta para ser desmanchada. Afirmou que o acusado portava ferramentas para desmontar veículos. Informou que, em diligências na casa do réu, foram encontrados as chaves mixas e o

capacete vermelho com viseira espelhada, além da moto do acusado e uma camiseta do Brasil, mesma roupa usada por ele na subtração de uma das motos, segundo consta das imagens registradas por câmeras de segurança.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Giovani, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), negou a prática dos furtos. Disse que comprou a motocicleta apreendida com Tiago Rodhigeiro como um veículo 'NP', não sabendo que se tratava de moto roubada. Afirmou que comprou a moto de uma pessoa desconhecida que ficava no supermercado 'Superbom', tendo pago mil reais. Informou que sabia que a documentação estava atrasada. Informou que os policiais não tinham autorização para entrar na casa de Tiago. Esclareceu que havia uma bolsa com algumas ferramentas, tais como chaves de fenda, chaves Philips e chaves de roda, que usava para arrumar sua moto. Mencionou que as chaves mixas encontradas não eram de sua propriedade. Citou que sua mãe possui uma Tucson de cor prata. Asseverou que, na delegacia, foi ameaçado a confessar a prática dos furtos. A prova colhida denota que furtos eram praticados em janeiro de 2021.

No presente feito, três deles restaram apurados.

Apenas a motocicleta do ofendido Thiago Henrique Vilela foi recuperada.

Depois, a ofendida Kemelly Cunha de Mello afirmou que conseguiu filmagens de câmeras de vigilância, e, por elas, o modus operandi ficou caracterizado.

Por isso, apenas dois delitos de furto restaram delineados (ofendidos Thiago Henrique Vilela e Kemelly Cunha de Mello).

A outra vítima Andréia Borges nem sequer elucidou a dinâmica delitiva ou mesmo reconheceu o acusado.

Os policiais civis mencionaram que os furtos cometidos na cidade ocorriam através de uma moto vermelha ou mediante a utilização de uma SUV/Prata.

Após, apurou-se que a mãe do acusado possuía uma Hyundai/Tucson da mesma cor.

A dinâmica delitiva dos crimes restou elucidada, através de câmeras de vigilância, pelas quais, os crimes eram cometidos por duas pessoas, sendo que uma delas sempre

chegava em uma moto vermelha.

Tal motocicleta, como afirmado nas próprias alegações finais, tem o acusado como possuidor.

Além disso, a testemunha Tiago Fernando Rodigheiro, responsabilizado pelo delito de receptação, em cuja casa os policiais apreenderam a motocicleta da vítima Thiago, afirmou aos policiais que o acusado havia furtado a motocicleta, com a seguinte citação (fls. 17): "que não fui eu quem furtou a moto; que quem furtou a moto foi o Giovani há dois dias atrás; que eu guardei a moto mesmo sabendo que era produto de furto; que o Giovani pediu para eu guardar a moto para ele no sábado; que nesta eu estava com Giovani porque eu fui levar ele para buscar na minha casa porque eu disse que não queria ela lá";

Tal declaração encontra arrimo na prova colhida, especialmente pelo fato de que, na casa do acusado, foram apreendidos chaves mixa (três delas), capacete vermelho de viseira espelhada, além da camisa do Brasil utilizada na dinâmica delitiva, peça de vestuário bem peculiar, pois de cor preta e com a menção "Brasil" nas costas, itens observados pelas câmeras de segurança colhidas pela ofendida Kemelly Cunha de Mello (auto de exibição e apreensão de fls. 19/20).

Aqui, importante mencionar que as chaves "mixas" foram submetidas à exame pericial (fls. 201/207), com a seguinte conclusão: "Os objetos mencionados acima de forma como foram apresentados, poderiam ser utilizados como "chave mixa" para prática de Furto, desde que manuseados por mãos hábeis para tais fins".

Por isso, os furtos são caracterizados por duas qualificadoras, quais sejam, concurso de agentes (delineado por depoimentos e filmagens) e com emprego de chave falsa.

No sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DO CRIME DO ART. 307. RES FURTIVA COFRE. VALOR R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS). 12 (DOZE) CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO FORAM SUFICIENTES A COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS PATRIMONIAIS.

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1- O recurso especial interposto com amparo no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado acórdão paradigma. Precedente AgRg no REsp 1453786/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 30/3/2015.

2- Na hipótese de tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, c/c art. 14, II, do CP) praticada por acusado reincidente, inviável é o reconhecimento do crime bagatela, dada a maior reprovabilidade da conduta (Precedente AgRg no REsp 1464228/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 3/12/2014).

3- Tentativa de furto qualificado. Emprego de chave falsa. Concurso de pessoas, crime de falsa identidade (art. 307 do CP), situação fática que levou o Tribunal local ao entendimento de que o recorrente possui personalidade moralmente deformada e direcionada à prática de crimes, sobretudo patrimoniais, de maneira que as condenações anteriores não tiveram o condão de afastá-lo do crime, razão pela qual "fixar penas mais brandas configuraria estímulo à prática criminosa", impossibilitando a aplicação do princípio da insignificância.

4- Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 623288 / SP, relator ministro Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 28/04/2015)

A alegação de desclassificação para receptação culposa também não deve prosperar. Da prova colhida, em momento algum restou comprovado que o acusado comprou a motocicleta desmontada.

Aliás, tampouco restou elucidado os motivos pelos quais o bem estava desmontado no imóvel de terceiro.

Em outras palavras, o ônus da licitude referente a tais alegações é defensivo, do

qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1244089 / DF, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA COM VISTAS A ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

(...)

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 979486 / MG, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/03/2018)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos no art. 155, §4º, III e IV do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Furto qualificado – Vítima Thiago Henrique Vilela

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por fim, uma das duas qualificadoras deve ser utilizada como “circunstâncias” que denotam a forma do cometimento do crime, forte no princípio da individualização da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE NAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES.

POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA APLICADA FUNDAMENTADAMENTE COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RÉU QUE SE VALEU DA SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA A PRÁTICA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes.

2. Uma vez reconhecida a incidência da qualificadora do abuso de confiança pelo Tribunal de origem fundamentadamente com base na prova dos autos no sentido de que comprovada diante das declarações do corréu e no fato de que ambos eram

funcionários da empresa vítima, valendo-se dessa condição para a prática do delito, inexistente ilegalidade a ser sanada.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1920453 / SP, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 11/05/2021)

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a r. jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Furto qualificado - Vítima Kemelly Cunha de Mello

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A culpabilidade não transborda as barreiras do tipo.

Como dito, uma das duas qualificadoras deve ser utilizada como "circunstâncias" que denotam a forma do cometimento do crime, forte no princípio da individualização da pena.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, a ofendida Kemelly não recuperou sua motocicleta.

Portanto, as consequências são perniciosas, a ponto de elevar a pena em mais 1/6, atingindo 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) diárias.

Na intermediária, afastada a agravante do "estado pandêmico", como fundamentação já lançada.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Os dois delitos foram cometidos no mês de janeiro.

Depois, com o mesmo modus operandi e sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, configurado o "crime continuado", nos termos do art. 71 "caput" do Código Penal.

Portanto, a pena mais grave deve ser exasperada em 1/6, atingindo, em definitivo, 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "c" e §3º do Código Penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, "C", e § 3º, DO CP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Para o julgamento, por esta Corte Superior, de agravo regimental em matéria penal, não cabe intimação da defesa acerca da data em que será realizada a respectiva sessão de julgamento, nem haverá, em regra, sustentação oral.

3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas duas circunstâncias do art. 59 do Código Penal - maus antecedentes e utilização de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria -, o que permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.

5. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", c/c § 3º, do Estatuto Repressor.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 690703 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 08/02/2022)

As reconhecidas circunstâncias em que o delito foi cometido, ou seja, com a presença de duas pessoas, emprego de chaves falsas, além do fato do acusado ter sido surpreendido na casa do receptador, onde a motocicleta apreendida já estava, inclusive, desmontada, denotam que a substituição da privativa por restritivas de direitos seria insuficiente, nos termos do art. 44, III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GIOVANI BARBOSA TORCIANO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, III e IV (duas vezes), c.c. 71 "caput", todos do Código Penal.

O acusado responde solto ao processo, por isso, assim deve permanecer neste momento processual, pois não se vislumbra os pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar.

Por fim, a motocicleta apreendida de cor vermelha, placas DRW6338 não pode ser restituída.

Com efeito, foi ela utilizada durante a prática criminosa, por isso, irrelevante que já tenha sido periciada.

Depois, tem como proprietário Daniel Felipe Torciano Thomaz.

Com efeito, o registro perante o DETRAN não serve para "mero registro administrativo" para fato gerador de tributo.

Eis a redação do art. 120 "caput" do CTB: "Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei".

Ou seja, diversamente do alegado, a propriedade é fator preponderante pelo Código de Trânsito, tanto é que, em caso de eventual transferência, novo certificado deve

ser emitido (art. 123, I).

Por isso, o pleito não pode ser deferido por ausência de legitimidade.

Quando muito, o que apenas é citado a título de argumentação, seria caso de aplicação do art. 120, §4º do CPP, com remessa das partes do Juízo Cível para apuração do “verdadeiro dono” (isto é, o detentor da propriedade registrada = domínio).

Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA (fls. 19/20).

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA